



P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

www.cef.es

info@cef.es

902 88 89 90

Índice Tema 20

1. Los órganos de las Administraciones Públicas.
 - 1.1. Creación.
 - 1.2. Competencia.
 - 1.2.1. Concepto y naturaleza.
 - 1.3. Delegación.
 - 1.4. Avocación.
 - 1.5. Encomienda de gestión.
 - 1.6. Delegación de firma.
 - 1.7. Suplencia.
 - 1.8. Coordinación y comunicaciones.
 - 1.9. Instrucciones y órdenes de servicio.
 - 1.10. Órganos colegiados. Régimen jurídico. Composición. Convocatorias, sesiones y actas.
 - 1.11. Régimen jurídico.
 - 1.12. Composición.
 - 1.13. Convocatorias, sesiones y actas.
 - 1.14. Abstención y recusación.



www.cef.es

P.º Gral. Martínez Campos, 5
Gran de Gràcia, 171
Alboraya, 23
Ponzano, 15

info@cef.es

28010 MADRID
08012 BARCELONA
46010 VALENCIA
28010 MADRID

Tel. 914 444 920
Tel. 934 150 988
Tel. 963 614 199
Tel. 914 444 920

902 88 89 90

TEMA 20

Los órganos de las Administraciones Públicas. Principios generales y competencia. Órganos colegiados. Abstención y recusación.

1. LOS ÓRGANOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Toda Administración Pública es un conjunto de elementos personales y materiales ordenados en unidades a las que se les asigna una parte de las competencias que corresponden a la organización en su conjunto.

A estas unidades se les denomina con las expresiones «órgano» y «oficio», haciéndose referencia, con la primera, al titular o funcionario y, con la segunda, al conjunto de medios materiales y atribuciones que la integran.

También hay quien considera que entre ambas expresiones no hay diferencia alguna ya que una y otra comprenden tanto al titular físico como a los medios materiales y a sus funciones.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJPAC), distingue al órgano de las unidades administrativas, dando a entender en su artículo 11 que el órgano integra una o varias unidades administrativas. Esta Ley considera al órgano como una estructura administrativa con atribución de competencias y con posibilidad de dictar actos administrativos.

En todo caso, la teoría del órgano se formula para explicar, a raíz del reconocimiento de la personalidad jurídica del Estado, el mecanismo de imputación a este de la actividad de las personas que actúan en su nombre.

La primera teoría formulada fue la de la representación voluntaria, según la cual el funcionario es un simple mandatario de la Administración, que establece la representación cuando quiere, según su voluntad.

Más tarde, la institucionalización de la Administración llevó a la teoría de la representación necesaria: la Administración no puede actuar si no es a través de funcionarios. La doctrina de la representación necesaria fue criticada por cuanto:

- El representante actúa en nombre y lugar del representado, cuya voluntad exterioriza. En cambio, el agente administrativo forma él mismo una voluntad que es imputable a la Administración y la obliga de forma inexorable.
- En la teoría de la representación es necesario que exista un representado, pero en la organización administrativa no hay tal: el funcionario actúa como parte integrante de la propia Administración, con la que se identifica.

La teoría de la representación no pudo resistir estas objeciones y ello hizo acudir a la doctrina a formular una nueva teoría: la del órgano.

Según Jellinek, la organización administrativa se resuelve en órganos que son parte integrante de la Administración, cuya voluntad exteriorizan, cuya titularidad corresponde a las personas físicas que están a su cargo. Esta teoría resolvió dificultades que no podía resolver la doctrina de la representación y, en particular, la permanencia de los cargos públicos a pesar de la desaparición o sustitución de sus titulares.

La teoría del órgano, si bien servía para explicar la relación entre la Administración y sus órganos, no valía, en cambio (igual que ocurría con la de la representación en este aspecto) para explicar la posición que ocupaba el titular del órgano, el funcionario, en cuanto que al mismo tiempo de ser sujeto activo de unas competencias como elemento subjetivo de la Administración, es sujeto pasivo de derechos y obligaciones frente a la Administración, distintas y especiales a las de las restantes personas físicas.

Por ello, la construcción bipartita Administración-órgano, debe ser sustituida por la tripartita: Administración-órgano-titular del órgano. Este fue el papel de la teoría del órgano y del oficio público, que trata de resolver el problema de la personalidad del órgano. Según esta tesis:

- El órgano es una entidad abstracta a la que se atribuye, no una personalidad, sino un haz de competencias.
- El titular del órgano, el funcionario, tiene por razón de oficio la personalidad jurídica necesaria para ejercer la competencia propia del órgano al que está adscrito.

La doctrina posterior abandonó esta tesis, ya que llevaba a confundir frecuentemente los conceptos de órgano y oficio.

García Trevijano mantiene que hay que volver a la teoría del órgano completándola con una referencia a la persona titular del órgano. Así, dejando como válida la teoría del órgano, deben definirse las relaciones entre el órgano y el titular del mismo. Estas relaciones pueden ser de dos tipos: relación de servicio y relación orgánica, siendo la primera presupuesto de la segunda: el funcionario es titular de un órgano (relación orgánica) porque se encuentra en un estatus legal especial que le habilita para aquella titularidad (relación de servicio). Por lo tanto, de la relación de servicio nace el estatuto del funcionario; de la relación orgánica nace la investidura del funcionario con las competencias del órgano, de forma que actúe frente a los administrados por y para la Administración.

Según el artículo 5.º 2 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE):

«Tendrán la consideración de órganos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.»

1.1. CREACIÓN.

El artículo 11 de la LRJPAC establece al respecto lo siguiente:

Artículo 11. Creación de órganos administrativos.

1. Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su propio ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.
2. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:
 - a) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
 - b) Delimitación de sus funciones y competencias.
 - c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
3. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos».

La remisión que el citado artículo 11 hace al régimen jurídico de cada una de las Administraciones Públicas determina analizar cada una de ellas por separado.

A) Administración estatal.

La reserva de Ley se ha impuesto para la regulación del Gobierno (art. 98 de la Constitución, la cual se realiza por medio de la Ley 50/1997), del Consejo de Estado (Ley Orgánica a tenor del art. 107) y de Organismos Públicos (art. 61 de la LOFAGE).

Respecto a los Ministerios y las Secretarías de Estado, en cuanto a su número, denominación y ámbito de competencia se establece mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno (art. 8.º 2 de la LOFAGE).

Respecto a los órganos y unidades administrativas, el artículo 10 de la LOFAGE, establece:

- «1. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas.
2. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas.
3. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.

La creación de todo órgano administrativo que suponga un incremento del gasto público irá precedido por un estudio económico del coste de su funcionamiento y del rendimiento o utilidad de sus servicios, así como de la posibilidad de aprovechamiento de los medios de otras administraciones, en evitación de un incremento injustificado de gasto público.»

B) Administración autonómica.

En cuanto a los órganos de las Comunidades Autónomas, habrá que atender a lo que digan las leyes sobre gobierno y administración dictadas en desarrollo de sus respectivos Estatutos. La regla general, dentro de la inevitable variedad, es la necesidad de ley autonómica para la creación de Departamentos o Consejerías, así como de Organismos autónomos de la Comunidad, correspondiendo la creación de los órganos inferiores a los respectivos Gobiernos autonómicos. Con carácter general basta, sin embargo, una Orden de la Consejería correspondiente para la creación, modificación o supresión de órganos iguales o inferiores a Sección, y en algunos casos a Servicio.

En el ámbito de la Comunidad Autónoma Valenciana, habría que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Su Ley de Gobierno (Ley 5/1983, de 30 de diciembre), establece en su Título IV, artículos 64 y siguientes, lo siguiente:

«Artículo 64.

Se aprobará por el Consejo un reglamento orgánico de cada Consejería a propuesta del Consejero respectivo.

Artículo 65.

La Presidencia de la Generalitat y los Consellers desarrollarán orgánicamente su propia Consellería o Departamento en los términos de su reglamento orgánico y demás normas reglamentarias que apruebe el Consell.

Artículo 66.

La organización de las Consellerías se estructura en tres niveles: Órganos Superiores, nivel directivo y nivel administrativo.

Artículo 67.

Los Órganos Superiores del Departamento son el Conseller y los Secretarios Autonómicos.

El nivel directivo lo integran los Subsecretarios, Directores generales y demás altos cargos que ostenten el rango de Director general.

Artículo 72.

El nivel administrativo se organizará en subdirecciones generales, servicios, secciones, unidades y negociados, pudiendo establecerse otras unidades cuando así fuese necesario.»

C) Administración Local.

Los órganos políticos básicos de los Municipios y Provincias (Pleno, Alcalde, Comisión de Gobierno, Pleno y Presidente de la Diputación) se encuentran creados ya por la propia Constitución en su artículos 140 y 141; y son regulados por la Ley de Bases de Régimen Local. Los órganos inferiores, ya de nivel administrativo, se regulan por cada corporación, que ha de aprobar un Reglamento orgánico, el cuál es de carácter supletorio a las previsiones que en materia de organización municipal dicten las Comunidades Autónomas en desarrollo de la Ley de Bases, tal y como se fijó por la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 214/1989.

1.2. COMPETENCIA.

1.2.1. Concepto y naturaleza.

Cuando se produce la creación de un ente se le dota de la aptitud para ser titular de determinadas relaciones jurídicas (capacidad jurídica) pudiendo estar instrumentada esta atribución sobre la base del principio de especialidad (Organismos Autónomos) o sobre el principio de generalidad [Municipio: art. 101 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL)]. Si además de la posibilidad se le atribuye la realidad de determinadas actividades, surge la titularidad.

Para actuar, un ente necesita hacerlo a través del órgano. Por ello, la competencia es simplemente la localización interna, dentro del ente, de las facultades, poderes y potestades atribuidos al mismo. García Trevijano la define como el conjunto de poderes, facultades y atribuciones que corresponde a un órgano en relación con los demás.

La competencia es una conquista del constitucionalismo moderno. El Estado absoluto solo conocía un centro de imputaciones: el Monarca, titular absoluto de todas las competencias. Por supuesto, que estas no eran ejercitadas por él, sino a través de otros sujetos que actuaban en nombre del Monarca y cuya legitimación nacía de un acto de este. Para que surja la competencia es necesario que la medida de la posibilidad y deber de actuar de cada órgano venga delimitada por la norma.

La competencia es un conjunto de facultades, deberes y atribuciones. El órgano competente no solo puede sino que además, dados de los presupuestos, debe actuar. Esto, sin embargo, no significa que la competencia sea una carga (Trevijano), porque no se trata de un imperativo del propio interés (la Administración es un *munus*, actúa intereses de terceros, por ello no hay autonomía de la voluntad sino, como mucho, discrecionalidad). La competencia, por ello, se instrumenta a través de cuatro principios cardinales:

- a) El de la irrenunciabilidad: el artículo 12 de la LRJPAC establece que «la competencia es irrenunciable y se ejercerá por aquellos órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación previstos en las leyes». Esto es lo que hace que la delegación y la posibilidad de avocar no se presuman nunca.
- b) El de especialidad: cada órgano debe actuar dentro de su competencia. Este principio tiene especial significación en materia de contratación administrativa.
- c) El de legalidad: debe actuarse de conformidad con la norma. Piénsese en materia de interdictos versus Administración y en el concepto de acto separable.
- d) Principio de finalidad: es decir, actuar para el fin que el ordenamiento ha previsto [piénsese en la desviación de poder, esto es, el ejercicio de competencias para fines distintos de los previstos en el ordenamiento jurídico: art. 70.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA)].

El artículo 12 de la Ley 30/1992 establece lo siguiente:

«Artículo 12. Competencia.

1. La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en esta u otras leyes.

La encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
3. Si alguna disposición atribuye competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio, y, de existir varios de estos, al superior jerárquico común.»

El artículo 20 de la Ley 30/1992 establece:

«Artículo 20. Decisiones sobre competencia.

1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si este pertenece a la misma Administración Pública.
2. Los interesados que sean parte en el procedimiento, podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente.

Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto.

3. Los conflictos de atribuciones solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.»

1.3. DELEGACIÓN.

El artículo 13 de la Ley 30/1992, en la redacción dada por la Ley 4/1999, establece al respecto:

«Artículo 13. Delegación de competencias.

1. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de aquellas.

2. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a:

- a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, Presidencia del Gobierno de la Nación, Cortes Generales, Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
- b) La adopción de disposiciones de carácter general.
- c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.
- d) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.

3. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el "Boletín Oficial del Estado", en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de este.

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

5. Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.

No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un asunto concreto una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

6. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.

7. La delegación de competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio ordinario se requiera un quórum especial, deberá adaptarse observando, en todo caso, dicho quórum.»

La Ley 5/1983, de Gobierno Valenciano, contempla esta técnica en el artículo 63, que tiene el siguiente contenido:

«Artículo 63.

- 1. El ejercicio de las competencias propias de cada órgano podrá ser delegado por este en el órgano jerárquico inmediato inferior, salvo que por la aplicación del principio de eficacia sea aconsejable atribuirlo a otro órgano, sin que quepa la delegación de competencias delegadas.
- 2. Las competencias propias del Consell son delegables en cualquier caso en las comisiones delegadas del Consell.
- 3. No son delegables las siguientes competencias:
 - a) Las que procedan de una atribución expresa del Estatuto de Autonomía.
 - b) Las que corresponden a los consejeros en su condición de miembros del Consell.

- c) Las que correspondan a relaciones con órganos del Estado de otras Comunidades Autónomas o Les Corts.
- 4. Las delegaciones realizadas por órganos del nivel administrativo requerirán autorización previa del Consejo.
- 5. Las delegaciones podrán ser revocadas en cualquier momento por el órgano delegante.
- 6. Las delegaciones y sus renovaciones deberán ser publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, y en las resoluciones adoptadas por la delegación deberá hacerse constar este extremo.»

1.4. AVOCACIÓN.

El artículo 14 de la Ley 30/1992 establece al respecto:

«Artículo 14. Avocación.

- 1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.

En los supuesto de delegación de competencias en órganos no jerárquicamente dependientes, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante.

- 2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte.

Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.»

1.5. ENCOMIENDA DE GESTIÓN.

El artículo 15 de la Ley 30/1992 establece al respecto:

«Artículo 15. Encomienda de gestión.

- 1. La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de la misma o de distinta Administración, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño.
- 2. La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

3. La encomienda de gestión entre órganos administrativos o Entidades de Derecho público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades intervinientes. En todo caso el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicado, para su eficacia en el "Diario Oficial" correspondiente.

Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

4. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local.
5. El régimen jurídico de la encomienda de gestión que se regula en este artículo no será de aplicación cuando la realización de las actividades enumeradas en el apartado primero haya de recaer sobre personas físicas o jurídicas sujetas a derecho privado, ajustándose entonces, en lo que proceda, a la legislación correspondiente de contratos del Estado, sin que puedan encomendarse a personas o Entidades de esta naturaleza actividades que, según la legislación vigente, hayan de realizarse con sujeción al derecho administrativo.»

1.6. DELEGACIÓN DE FIRMA.

«Ley 30/1992. Artículo 16. Delegación de firma.

1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de su propia competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites señalados en el artículo 13.
2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de procedencia.
4. No cabrá la delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador.»

1.7. SUPLENCIA.

El artículo 17 de la Ley 30/1992 establece al respecto:

«Artículo 17. Suplencia.

1. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad por quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquellos.

Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato de quien dependa.

2. La suplencia no implicará alteración de la competencia.»

El inciso «por quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquellos» ha sido declarado no básico por la STC 50/1999.

1.8. COORDINACIÓN Y COMUNICACIONES.

Los artículos 18 y 19 de la Ley 30/1992 establecen al respecto:

«Artículo 18. Coordinación de competencias.

1. Los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias propias ajustarán su actividad en sus relaciones con otros órganos de la misma o de otras Administraciones a los principios establecidos en el artículo 4.º 1 de la Ley, y la coordinarán con la que pudiera corresponder legítimamente a estos, pudiendo recabar para ello la información que precisen.
2. Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

Artículo 19. Comunicaciones entre órganos.

1. La comunicación entre los órganos administrativos pertenecientes a una misma Administración Pública se efectuará siempre directamente, sin traslados ni reproducciones a través de órganos intermedios.
2. Las comunicaciones entre los órganos administrativos podrán efectuarse por cualquier medio que asegure la constancia de su recepción.»

1.9. INSTRUCCIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO.

El artículo 21 de la Ley 30/1992 establece al respecto:

«Artículo 21. Instrucciones y órdenes de servicio.

1. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio.

Cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el periódico oficial que corresponda.

2. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.»

1.10. ÓRGANOS COLEGIADOS. RÉGIMEN JURÍDICO. COMPOSICIÓN. CONVOCATORIAS, SESIONES Y ACTAS.

El régimen jurídico de los órganos colegiados viene regulado en el Capítulo II del Título II de la LRJPAC (arts. 22 a 29), sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.

El Tribunal Constitucional, en Sentencia 50/1999, de 6 de abril, ha declarado inconstitucionales los siguientes artículos: 17.1, inciso «por quien designe el órgano competente para el nombramiento de aquellos»; 23.1 y 2, 24.1, 2 y 3, 25.2 y 3, 27.2, 3 y 5, al considerar que el Estado invadía competencias de las Comunidades Autónomas.

Frente al órgano unipersonal, el órgano colegiado se caracteriza porque su titularidad corresponde a un conjunto de personas físicas. La voluntad del órgano colegiado se forma por el concurso de la voluntad de esa diversidad de miembros sin que por ello el acto del órgano deje de ser un acto simple y no complejo, que es aquel en que concurre la voluntad de diversos órganos, sean unipersonales o colegiados.

La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 estableció, por primera vez en nuestro ordenamiento, una regulación de los aspectos estructurales de los órganos colegiados, que ha sido sustituida por la de los artículos 22 a 29 de la LRJPAC, pero que no es aplicable a los órganos colegiados máximos o directivos de cada Administración: Gobierno de la Nación, Gobiernos o Consejos de Gobiernos Autonómicos, Plenos de los Entes Locales (disposición adicional primera). En definitiva, se está, en los dos primeros casos, ante órganos de carácter mixto, político y administrativo, que tienen su régimen jurídico específico: Ley 50/1997, Ley de Gobierno y Administración de cada Comunidad Autónoma; Ley 7/1985, Reguladora de las bases del régimen local.

Novedad de la regulación vigente es que impone una clasificación, un doble régimen jurídico de los órganos colegiados antes inexistente, distinguiéndose los órganos colegiados que podríamos denominar órganos colegiados comunes, del régimen de aquellos otros órganos colegiados en que participan organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones.

El primer efecto de esta división es que, mientras los órganos colegiados comunes integrados por autoridades o funcionarios de una misma Administración se insertan en la estructura jerárquica de cada Administración -aunque pueden ser órganos sujetos a una jerarquía debilitada, como es el caso de los órganos colegiados que ejercen funciones consultivas- aquellos en que se insertan miembros con una representación de intereses, no participan en la estructura jerárquica de esta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado (art. 22.2).

1.11. RÉGIMEN JURÍDICO.

El artículo 22 de la Ley 30/1992 establece al respecto:

«Artículo 22. Régimen.

1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en el presente Capítulo, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.

2. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Los órganos colegiados a que se refiere este apartado quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de esta, salvo que así lo establezcan sus normas de creación, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del órgano colegiado.»

1.12. COMPOSICIÓN.

Los artículos 23, 24 y 25 de la Ley 30/1992 establecían previsiones al respecto. Debe tenerse en cuenta que muchas de las previsiones de los mismos se han visto afectadas por la STC 50/1999, que las ha considerado no básicas y contrarias al orden constitucional de competencias por implicar una regulación de detalle que no deja espacio a las Comunidades Autónomas.

Conviene tener en cuenta, no obstante, que en el ámbito de la Administración del Estado dichos preceptos son de aplicación en cuanto que el artículo 38.3 de la Ley 6/1997, LOFAGE se remite a los mismos en los siguientes términos:

- «3. El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere el apartado 1 de este artículo se ajustará a las normas contenidas en el Capítulo II del Título II de la LRJPAC, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la presente ley o en su norma o convenio de creación.»

Por tanto, para la Administración del Estado, el régimen jurídico de sus órganos colegiados será el establecido en el Capítulo IV del Título II de la LOFAGE, y complementariamente, la Ley 30/1992, artículos 22 y siguientes.

Respecto de dicha Administración estatal indicar lo que los citados artículos establecen en materia de composición de órganos colegiados:

«Artículo 23. Presidente.

1. En cada órgano colegiado corresponde al Presidente:

- a) Ostentar la representación del órgano.
- b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros formuladas con la suficiente antelación.
- c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.
- d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los órganos colegiados a que se refiere el número 2 del artículo 22, en que el voto será dirimente si así lo establecen sus propias normas.
- e) Asegurar el cumplimiento de las Leyes.

- f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.
 - g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Presidente del órgano.
2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden, de entre sus componentes.

Esta norma no será de aplicación a los órganos colegiados previstos en el número 2 del artículo 22 en que el régimen de sustitución del Presidente debe estar específicamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del órgano colegiado.

Artículo 24. Miembros.

1. En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros:
- a) Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo.
 - b) Participar en los debates de las sesiones.
 - c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican.
- No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros de órganos colegiados.
- d) Formular ruegos y preguntas.
 - e) Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
 - f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición.
2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a este, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano.

3. En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.

Cuando se trate de órganos colegiados a los que se refiere el número 2 del artículo 22, las organizaciones representativas de intereses sociales podrán sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con respecto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organización.

Artículo 25. Secretario.

1. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.

2. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarán según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo.
3. Corresponde al Secretario del órgano colegiado:
 - a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto si es un funcionario, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.
 - b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano por orden de su Presidente, así como las citaciones a los miembros del mismo.
 - c) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
 - d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
 - e) Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
 - f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario.»

Para las Comunidades Autónomas dichos artículos no son aplicables, teniendo la posibilidad de establecer una autoconfiguración de sus órganos administrativos colegiados.

1.13. CONVOCATORIAS, SESIONES Y ACTAS.

La citada STC 50/1999 declara a su vez no básicas las previsiones sobre la cuestión del artículo 27.2, 3 y 5, siendo solo aplicables a la Administración del Estado. El resto de los artículos 26 y 27 sí tendrían carácter básico.

Los artículos 26 y 27 de la Ley 30/1992 establecen lo siguiente:

«Artículo 26. Convocatorias y sesiones.

1. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes le sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros, salvo lo dispuesto en el punto 2 de este artículo.

Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el número 2 del artículo 22, el Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si están presentes los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces.

2. Los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si este no está previsto por sus normas de funcionamiento.

Tal régimen podrá prever una segunda convocatoria y especificar para esta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano.

3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.
5. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos.»

Conviene tener en cuenta, en la medida en que dicho artículo sea aplicable, que muchas de estas previsiones son reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados, cuya infracción supone viciar el acto o decisión administrativa resultante con el vicio de nulidad de pleno derecho, en los términos del artículo 62.1 e) de la LRJPAC.

«Artículo 27. Actas.

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
2. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma.
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.
4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
5. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobación del acta se hará constar expresamente tal circunstancia.»

1.14. ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN.

Los artículos 28 y 29 establecen al respecto:

«Artículo 28. Abstención.

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

2. Son motivos de abstención los siguientes:

- a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
 - b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
 - c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
 - d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
 - e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
3. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurren motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente.
5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.

Artículo 29. Recusación.

1. En los casos previstos en el artículo anterior podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
2. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.
3. En el día siguiente, el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, el superior podrá acordar su sustitución acto seguido.
4. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.»

